

1500706-54.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... de Edilson e Hanes, pelo delito de tráfico de drogas; absolvição de Gustavo, por esse mesmo crime; e a absolvição do trio quanto ao delito de associação para o tráfico (fls. 467/475).

Com o mesmo entendimento, a defesa de Gustavo requereu sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime inicial mais brando e, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500706-54.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500706-54.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2204723/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 19318706 - 2º Distrito Policial de Lorena, 658/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2204723 - 02º D.P. LORENA, 658/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON CARLOS GONCALVES SANTANA JUNIOR e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de EDILSON CARLOS GONÇALVES SANTANA JÚNIOR, GUSTAVO HENRIQUE FELIZARDO JUNQUETTI e HANES HARIM NUNES SANT'ANNA FERREIRA DE LIMA, qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, combinados com o artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06. HANES HARIM NUNES SANT'ANNA FERREIRA DE LIMA foi ainda denunciado pelo crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03; conforme os fatos narrados na peça inicial de fls. 204/207.

Recebida a denúncia, em 07/05/2021 (fls. 214/216), os réus foram citados e

apresentaram as suas respostas à acusação (Hanes, às fls. 279/304; Edilson, às fls. 312/314, e Gustavo, às fls. 342/345). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 353/357).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas e os informantes judiciais arrolados pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a condenação do corréu Hanes, pelo crime do artigo 12, da Lei 10.826/03; condenação de Edilson e Hanes, pelo delito de tráfico de drogas; absolvição de Gustavo, por esse mesmo crime; e a absolvição do trio quanto ao delito de associação para o tráfico (fls. 467/475).

Com o mesmo entendimento, a defesa de Gustavo requereu sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime inicial mais brando e, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 480/483).

Por sua vez, a defesa de Edilson requereu a improcedência da ação penal, por carência probatória. Subsidiariamente, requereu igualmente o reconhecimento da figura privilegiada do tipo (artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06), com a imposição do regime inicial diverso do fechado, e com o direito de recorrer em liberdade (fls. 484/488).

Por fim, a defesa de Hanes também pugnou pela improcedência da ação penal. Em preliminar, suscitou a nulidade das provas, alegando que estas foram produzidas com violação à garantia domiciliar do réu. No mérito, sustentou inexistirem existirem provas de sua concorrência para os delitos, e que estas são insuficientes para condená-lo. Invocou o princípio da insignificância, em relação ao crime da Lei de armas, por apenas terem sido apreendidos cinco projéteis. Em caso de condenação, no entanto, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com possibilidade do recurso em liberdade, e que seja concedido o benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 493/514).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, refuto a preliminar invocada.

Este Juízo não desconhece o entendimento que vem se formando no Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévia autorização do morador da residência para incursão policial, em respeito ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Porém, entendo que a ação policial no caso em tela observou os limites da Constituição Federal.

Com efeito, a abordagem de veículos e a entrada de agentes das forças de segurança pública em domicílios motivados por notícias anônimas, é uma realidade, porém não se está convalidando uma ação policial apenas em razão da constatação, a posteriori, da prática de um crime permanente.

No caso destes autos, as provas demonstraram à exaustão, conforme se verá mais à frente, que os policiais militares determinaram que o condutor do veículo ocupado pelo trio de acusados (Hanes), o parasse para averigua-lo, por ser alvo de notícias anteriores envolvendo o transporte de drogas e arma de fogo. Atendida a ordem, Hanes, aproveitando-se do momento de desembarque dos agentes da viatura tratou de empreender fuga, circunstância que somente fortaleceu as fundadas suspeitas que já recaíam sobre os réus.

Na sequência e, após localizarem os entorpecentes e a arma de fogo no interior do automóvel, os agentes da lei dirigiram-se até a residência de Hanes, onde Maria Eduarda, ex-cunhada deste, e irmã de Edilson, autorizou que lá ingressassem, além de acompanhar as diligências.

Portanto, não há como taxar de ilegal ou ilegítima a ação policial, ora em voga.

Porém, ainda que Maria Eduarda não tivesse autorizado a entrada dos policiais, em virtude do estado flagrancial, vez que já haviam sido localizados ilícitos no interior do veículo que Hanes dirigia na ocasião, já alvo de suspeitas policiais anteriores, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, expressamente excepciona a inviolabilidade do domicílio.

Essas situações são tão corriqueiras e levantadas pelas defesas que, não à toa, o Supremo Tribunal Federal – STF debruçou-se sobre o assunto, em repercussão geral (Tema 280), estabelecendo diretrizes para o controle judicial em tais hipóteses:

Tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa, não se pode dizer que a conduta dos agentes públicos não estava baseada em fundadas razões (justa causa), nos termos dos artigos 240 e seguintes, do CPP.

Lado outro, descabe falar em usurpação de função pública por parte dos policiais militares que, em patrulhamento de rotina, e conhecedores de informações sobre a prática de um crime permanente diligenciam no local, a fim confirma-las, realizando simples abordagem em veículo e, após descobrirem a existência de narcóticos, dão continuidade às diligências na residência do criminoso, frise-se, com autorização de ocupante/moradora.

De fato, esses agentes estatais agem guiados pela obrigação decorrente do múnus por eles exercido e constitucionalmente previsto de preservar a ordem pública. Exigir conduta diversa desses policiais militares, funcionários públicos que são seria, para dizer o mínimo, omissão de caráter criminal, tipificado no artigo 319, do Código Penal.

A propósito, em recente julgado:

“Nulidade – Investigação pela Polícia Militar - Usurpação de função pública – Inocorrência – Policiais militares diligenciaram para confirmar informação relativa a delito praticado pouco tempo antes – Ausência de ilegalidade – Preliminar rejeitada. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500456-16.2021.8.26.0073; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022).

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

As materialidades dos delitos de tráfico de drogas e de armas encontram-se cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), fotografias (fls. 52/64), laudo de constatação provisória (fls. 91/96) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 193/196), cujos resultados foram positivos para “cocaína e tetrahidrocannabinol – THC – maconha”, substâncias presentes nas listas,

da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; laudo pericial da arma de fogo e das munições (fls. 440/444 e 437/439), cujo resultado atestou o potencial lesivo das munições e a eficácia do armamento, respectivamente; bem como pelas provas orais.

As provas de autoria destes dois crimes são igualmente certas, ao menos no que tange aos corréus Edilson e Hanes. Senão vejamos.

A informante judicial Maria Eduarda Gonçalves Barbosa, irmã de Edilson, contou que estava na casa de Hanes, seu ex-cunhado, quando policiais militares chegaram ao local, solicitando autorização para revista-lo. Disse que, de fato, autorizou a entrada dos agentes da lei no imóvel, acompanhando apenas dois deles, confirmando a localização das munições e entorpecentes, bem como outros apetrechos relacionados a arma de fogo e uma toca ninja. Questionada, disse que Hanes era o único morador do imóvel, e que lá estava, ocasionalmente, para encontrar sua namorada. Afirmou que o veículo Volvo era de propriedade de Hanes. Contou que viu Gustavo uma única vez saindo de carro com os Hanes e Edilson, acreditando que seria para jogarem bola juntos, não sabendo dizer se aquele era amigo da dupla. Por fim, esclareceu que Edilson era barbeiro, e que nunca o viu armado.

O cabo da polícia militar, André Luiz de Jesus da Silva declarou que durante patrulhamento de rotina, avistou um veículo da marca Volvo, alvo de denúncias anteriores que o relacionava ao transporte de arma de fogo e drogas. Assim, decidiu abordá-lo, a fim de averiguar a procedência das informações, dando sinal de parada ao condutor. Obedecendo a ordem, o motorista estacionou o automóvel, e quando dele se aproximava, aquele saiu em fuga, iniciando-se uma perseguição até que, em certo local, o carro novamente parou, momento em que um dos réus tentou sair em fuga, desta vez, a pé. Disse que conseguiu Hanes e o seu parceiro, os demais ocupantes do carro. De acordo com o depoente, no interior do veículo, foram localizadas drogas, balança de precisão e, na cintura de um dos réus (Edilson), uma arma de fogo. Contou que, após confissão informal de Hanes, foram até o seu endereço, local onde mais drogas e munições foram achadas. Questionado, explicou que Gustavo havia sido surpreendido dias antes, com terceiro estranho a esses autos, no contexto do vil comércio, e que "Juninho" (vulgo do corréu Edilson), já estava sendo denunciado, nos meios policiais, assim como Hanes. Negou que tenha realizado disparo de arma de fogo durante a perseguição à Hanes. A respeito de Gustavo, esclareceu que não havia notícias em seu desfavor, apenas informação no sentido de que ele havia sido preso em data anterior, por envolvimento com o tráfico. Afirmou que o calibre das munições localizadas na casa de Hanes era o mesmo da arma de fogo localizada na cintura de Edilson, no veículo. Por fim, sobre as supostas mensagens enviadas por Hanes, no momento que fugia do cerco policial, disse que não visualizara esse acusado enviando-as.

Seu companheiro de farda e de diligência, Danilo Rodrigues de Souza fez coro às suas declarações. Tal testemunha, porém, especificou que as drogas encontradas no veículo estavam escondidas em sua parte frontal, ao lado do carona, nada sendo encontrado na posse do corréu Gustavo.

Já a informante judicial Caroline do Nascimento Silva contou que Hanes enviara mensagem de socorro no dia dos fatos. Disse que o questionou sobre o que ocorria, no entanto, o réu não a respondeu. Assim, juntamente com Gabriela, resolveram ir à casa dele. Ao chegar ao imóvel, a informante viu que policiais militares lá estavam, diligenciando em seu interior. Embora Hanes tenha lhe pedido para acompanhar, a informante permaneceu na entrada da casa. Questionada, disse que os áudios juntados aos autos, em mensagens de aplicativo, foram enviados por ela.

A outra informante judicial ouvida, Maria Gabriela de Paula Ávila, apresentou versão semelhante. Esclareceu, porém, que os áudios foram trocados com o acusado pelo celular de Carolina, dizendo que Hanes mandou mensagem à elas, e não aos seus

familiares, pois haviam combinado de sair naquele dia. Questionada, disse que somente Carolina e ela foram até a casa dele, apenas vendo os familiares do réu na delegacia de polícia.

A testemunha de defesa, padre Roberto Carlos Albino disse que estava celebrando uma missa no momento dos fatos, quando ouviu um estampido semelhante ao barulho produzido por disparo de arma de fogo, não presenciando os fatos, todavia.

Uma outra testemunha, também arrolada pela defesa de Hanes, Anderson Rodrigo Fabiano, afirmou não ter presenciado os fatos, ouvindo por sua irmã Camila, que os policiais dispararam pelas costas de Hanes.

Por fim, a testemunha Romes Paulo Martins, testemunha do corréu Gustavo contou que no dia dos fatos, os familiares do acusado lhe pediram para comparecer ao local da ocorrência. Lá chegando, viu Gustavo algemado, ao lado da viatura policial. Questionado, disse que não presenciou o encontro de drogas e/ou armas, ouvindo dizer que disparos de arma de fogo foram realizados no local.

Passo a analisar os interrogatórios dos réus.

Edilson negou as acusações que lhe pesam. Disse que pegava uma carona com Hanes quando na altura dos Correios, policiais militares deram-lhe ordem de parada, a qual foi inicialmente acatada. No entanto, quando os agentes públicos se aproximavam do veículo, Hanes acelerou o carro, em fuga, não sabendo o motivo para Hanes assim agir. Disse que mais a frente, os policiais conseguiram aborda-los, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado com eles. De acordo com o interrogando, apenas no distrito policial os agentes da lei apresentaram uma arma de fogo e drogas. Questionado, disse que não conhecia os policiais militares até então. Sobre Gustavo, esclareceu que estava em sua companhia no banco Santander, e entraram no carro de Hanes juntos, ambos sentando no banco traseiro. Afirmou que o policial André Luiz realizou um disparo de arma de fogo. Ao cabo de sua autodefesa, disse que não leu as suas declarações prestadas em sede distrital.

O corréu Hanes foi outro a refutar as acusações que lhe são dirigidas. Contou que estava indo a uma festa em seu veículo, quando passou por uma viatura policial no trajeto. Negou, porém, que os agentes públicos tenham lhe dado ordem de parada, embora tenha observado que a viatura policial passou a lhe seguir. Assim, quando estava próximo aos Correios, decidiu parar o veículo. Nesse momento, quando os policiais aproximavam-se do automóvel para aborda-los, o quarto indivíduo que estava em seu interior lhe contou que estava armado, o que fez com que acelerasse o carro, com receio de ser preso. Disse que chegou a despistar os policiais, descendo do veículo, assim como o indivíduo armado, contudo, os policiais conseguiram localiza-lo e passaram a persegui-lo a pé. Afirmou que escutou dois disparos de arma de fogo e, com medo de ser morto pelos agentes públicos, invadiu a casa de um cliente do seu mercado, que lhe acolheu, momento em que começou a enviar as mensagens a diversas pessoas, inclusive, aos seus avós. O interrogando contou que recebeu mensagens dizendo que Pedro (o quarto ocupante do veículo), havia conseguido chegar em sua casa, porém, preferia continuar escondido naquele local, e também de Caroline, contando que havia policiais militares em sua casa. Afirmou que enquanto enviava mensagens por aplicativo de celular, a dona do imóvel onde se escondeu, avisou-lhe que os agentes da lei estavam o procurando e, mesmo correndo para dentro do banheiro, acabou sendo capturado. Disse que não acompanhou as diligências em seu veículo ou em sua casa, ficando separado dos corréus, e de Maria Eduarda, somente descobrindo na delegacia, a existência das drogas. Afirmou que o indivíduo que ocupava o banco do carona, e que o acompanharia na festa chamava-se Pedro Felipe Gonçalves, e era primo da sua ex-mulher e vizinho. Sobre Edilson e Gustavo, disse que os encontrou perto de sua casa, quando este último lhe pediu uma carona. Informou que durante a fuga, ninguém conversou dentro do veículo sobre o que estava acontecendo, e que visualizou Pedro saindo do carro e se evadindo, não

sabendo se ele levou a arma de fogo, ou a deixou no veículo. Disse que o carro Volvo é do seu avô.

Gustavo trilhou no mesmo sentido das negativas. Disse que havia comparecido ao banco Santander e, quando voltava à sua casa à pé, na companhia de Edilson, encontrou Hanes em seu carro, e lhe pediu uma carona. Afirmou que quando estavam todos no carro, a polícia deu sinal de parada, o que não foi obedecido por Hanes imediatamente. Disse não ter entendido o motivo da fuga. Mais a frente, quando Hanes parou o carro, este saiu correndo, enquanto permaneceu parado ao lado do veículo. Ato contínuo, foi abordado juntamente com Edilson. Nesse momento, ouviu um barulho parecido com o produzido por disparo de arma de fogo. Disse que os policiais nada encontraram no interior do carro.

Eis as provas dos autos.

Como se vê, as versões dos acusados e dos policiais militares são absolutamente antagônicas entre si.

Pois bem. Malgrado já tenha sustentado em decisões anteriores, nunca é demais reforçar a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, ou mesmo, qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que um policial; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso da militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria

daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, ele próprio, violá-la, com o fito de incriminar um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só. Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem, em desfavor dos acusados, sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, como no caso, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõe a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de uma pessoa se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que presenciou, por exemplo. Qual pai de família, em sã consciência, se apresentaria à autoridade policial e/ou ao juiz, para entregar um traficante? Ainda mais sabendo que continuará a residir no local dos fatos, hipótese destes autos, vez que os fatos ocorreram em um prédio, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas naquela região.

Diante disso, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. O mesmo vale para confissão do réu. Não nos encontramos mais nos primórdios do processo penal. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas. Todas são relativas!

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput" do CPP, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Não bastasse isso, verifico que os enredos defensivos apresentam incoerências e inconsistências, tornando ainda mais seguro, o testemunho dos agentes públicos, mantido ao longo de todas etapas da persecução penal.

Quanto ao corréu Edilson, observo que o acusado apresentou narrativa complementemente diversa em sede policial, ocasião em que contou que se encontrava no banco da frente do automóvel (carona), indo a uma festa com Hanes. Na oportunidade, o réu nada disse sobre disparos de arma de fogo por parte dos policiais militares, nem mesmo mencionando a existência de uma quarta pessoa no automóvel (Pedro), conforme se depreende às fls. 27.

Anote-se que a versão policial do acusado assemelha-se demasiadamente com à dos policiais militares, e com à do próprio Gustavo, igualmente em sede administrativa (p. 28), com exceção da apreensão das drogas, dos apetrechos e da arma de fogo municiada em sua cintura, que Edilson, por óbvio, continua negando.

No que tange à Gustavo, embora este também tenha negado que drogas foram encontradas no interior do veículo à autoridade policial, de outro lado, confirmou que os policiais lhes exibiram uma arma de fogo (pistola), no local de suas abordagens, contrariando a própria versão que deu em juízo.

Há que se apontar, outrossim, uma contradição entre a autodefesa de Edilson e de Hanes.

Decerto, conforme já visto alhures, em seu interrogatório, Hanes afirmou que Pedro (o tal quarto suposto ocupante do veículo), foi o responsável por lhe fazer acelerar o carro, após dizer que estava armado. Contudo, Edilson disse não saber a razão para Hanes se evadir da polícia, nada mencionando sobre o motivo alegado por este.

Assim, é o caso de encampar a tese acusatória, baseada na fala dos policiais, e sustentada desde o momento da prisão em flagrante, no sentido de que Edilson encontrava-se no banco do carona, local onde achados os narcóticos dentro do veículo, e com uma arma de fogo em sua cintura, esclarecendo-se que nenhuma das testemunhas de defesa presenciaram a busca realizada no veículo de Hanes, ou mesmo a abordagem dos acusados.

Sendo a tipificação atribuída à conduta de Edilson, importante mencionar que o porte do armamento se deu no contexto fático do transporte das drogas, de modo a garantir a segurança da vil empreitada. Logo, correta sua capitulação legal, já que o crime-meio é absorvido pelo delito-fim, de acordo com o princípio da consunção.

A propósito, em recente julgado:

“(...) Tráfico de Drogas - (...) Estatuto do Desarmamento - Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido- Afastamento por força do princípio da consunção - Crime-fim que absorve o crime-meio - Laudo pericial a atestar a eficácia da arma de fogo ao disparo (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1502218-67.2020.8.26.0537; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022) (Sublinhado meu).

Registre-se o laudo pericial realizado na arma de fogo atestou seu potencial para disparos (fls. 440/444).

Portanto, a condenação do acusado é medida que se impõe, nos termos da denúncia (artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal).

Com relação ao corréu Gustavo, a prova reunida em seu desfavor não é suficiente para condena-lo.

Com efeito, o que se tem nos autos, é que o réu encontrava-se apenas no mesmo

veículo dirigido por Hanes, sentado no banco traseiro, nada sendo encontrado em sua posse, ou ainda perto do local onde estava no interior do automóvel.

Além disso, saliente-se que o acusado desde a fase policial sustentou que estava no banco traseiro do carro, e apenas pegando uma carona com Hanes, diferentemente de Edilson (fls. 27/28).

Assim, forçoso reconhecer que a prova aqui formada não é sólida, devendo a dúvida favorecer-lo.

Portanto, em prestígio ao consagrado princípio in dubio pro reo, a única solução é a sua absolvição.

Por fim, no que tange ao corréu Hanes, a prova acusatória é implacável quanto ao tráfico.

A postura do acusado seria muito inusitada, se houvessem nos autos, tantas e robustas provas em seu desfavor, como as mensagens e áudio de supostas conversas mantidas com terceiros.

Como não bastasse o fato de ser o motorista e possuidor do veículo, alvo de denúncias anteriores que o relacionava ao transporte de drogas, frise-se, responsável por fugir da polícia; e ainda de ser o morador do imóvel onde mais entorpecentes, apetrechos e munições foram encontrados, o acusado sequer logrou provar o que alegou em Juízo, como a existência de uma quarta pessoa no interior do carro que guiava, por exemplo.

Veja-se que sua defesa chegou a juntar nos autos, supostas mensagens que teria enviado a terceiros e familiares, enquanto supostamente se escondia da polícia (fls. 305/311, 426/429 e 430/431).

Ocorre que, a despeito da ausência de comprovação da autenticidade de tais mensagens, o que não se pode afirmar de modo algum, da simples leitura e oitiva dos áudios, percebe-se que o réu não só sabia que estava transportando ilícitos em seu carro como igualmente guardava mais drogas e munições em sua residência.

Como se vê no seguinte trecho (fls. 305/311), em tese, diálogo mantido entre Hanes e pessoa não identificada (PNI), possivelmente a informante judicial Caroline:

"(...)

Hanes: Fugi da policia

E deixei o carro pa tras"

PNI:Tô na rua já

Com o Vitor

Posso entrar?

Hanes: Entra na ond

Não

PNI:Moioooo

As viaturas tá aqui na porta da sua casa

Hanes:Entraram

?

PNI: (Áudio enviado)

(...)

PNI:Moio real

Hanes:V c eles vai sair com as coisas

PNI: Tinha alguém lá dentro?

Hanes:Tem."

Os áudios apócrifos, igualmente sem qualquer indicação de cronologia, são mais

elementos a demonstrar o acerto da linha acusatória, pois a todo tempo (Hanes, supostamente) é advertido para não retornar para casa, mas continuar fugindo.

Inclusive, é em um desses áudios (fls. 430), com voz masculina (logo, não oriundo das conversas mantidas, em tese, com as informantes judiciais Caroline e Maria Gabriela - fls. 305/311), que há menção a um suposto "Pedrão".

Todavia, sem o contexto da conversa, não é possível afiançar que o tal "Pedrão" encontrava-se dentro do veículo, sendo o único responsável pelos ilícitos, especialmente diante do comportamento apresentado pelos corréus Hanes e Edilson, tal como exaustivamente fundamentado acima, sem contar ainda, o fato da apreensão de mais drogas na casa de Hanes, e a arma de fogo na cintura de Edilson.

Por oportuno, tal como fundamentado acima, a arma de fogo apreendida na cintura de Edilson configura a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, majorante esta que se comunica à Hanes, já que ambos transportavam as drogas em evidente concurso de agentes, com unicidade de contexto fático.

Por fim, a respeito do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, esclareço ser desnecessário para sua configuração que o agente seja flagrado em atos de mercancia, à luz da variedade de ações nele previstas. No caso dos autos, as condutas de transportar as drogas no veículo, e aquela de guardar entorpecentes na residência de Hanes restaram devidamente caracterizadas, estando a finalidade mercantil perfeitamente delineada nos autos pelas circunstâncias do caso concreto, diante das quantidades e diversidade de entorpecentes; do encontro de apetrechos, como balança de precisão no veículo e pinos plásticos do tipo eppendorff, vazios na casa, indicando sem sombra de dúvidas o fim mercantil daquelas drogas.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Destarte, deve o réu igualmente ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, em comparsaria.

Mesmo destino condenatório terá quanto ao crime de posse ilegal de munições, já que estas foram encontradas em sua casa, estando sob sua responsabilidade.

Como se sabe a exigência legal de regularização dessas munições não é mera burocracia estatal, é garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam arma de fogo, munições, como no caso, ou acessório.

Ressalto, também, que o crime de posse irregular de munições é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime

previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido". (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Logo, para o reconhecimento da autoria de tal delito, basta a vontade livre e consciente de possuir arma, munições ou acessórios sem a devida autorização legal, o que ficou evidente no presente caso, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação e da informante judicial Maria Eduarda.

Destaque-se que o laudo pericial acostado aos autos (fls. 437/439), atestou que as munições foram percutidas, detonadas e deflagradas nos testes, demonstrando-se o potencial lesivo das mesmas.

Não há que se falar em ausência de tipicidade material de tal conduta, com base na quantidade de munições apreendidas na casa de Hanes, até porque localizados outros acessórios de arma de fogo, como um coldre.

Afinal, se a posse de acessório, por si só, já é punida por esse tipo penal, não faz qualquer sentido isentar o acusado da pena pela posse de munição, ainda que de apenas cinco projéteis, conduta mais gravosa e lesiva ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, o entendimento recente do nosso Tribunal de Justiça, em fatos com menor quantidade de munições do que o ora em julgamento:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (406 PINOS DE COCAÍNA, 01 INVÓLUCRO DE MACONHA E 05 PEDRAS GRANDES DE "CRACK") – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO, TAMBÉM, POR POSSE DE MUNIÇÕES (03 CÁPSULAS DE CALIBRE 22) (...) – IMPÕE-SE, TAMBÉM, A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES, AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1501248-21.2020.8.26.0617; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022) (Original sem marcação).

Ademais, insta salientar que, embora em outro contexto fático, foi apreendida arma de fogo municiada na posse de seu comparsa, ora corréu Edilson, do mesmo calibre das munições localizadas dentro de sua casa.

E não é só: as munições estavam guardadas com mais diversas drogas e apetrechos do vil comércio, como milhares de pinos plásticos, do tipo eppendorf, vazios; não sendo cabível se falar em insignificância nesse contexto criminoso de pluralidade de delitos.

A propósito, em julgado do Superior Tribunal de Justiça semelhante ao caso destes autos:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do

caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). 3. Diante de tais precedentes, a Quinta Turma desta Corte vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 4. No presente caso, o acusado portava 5 munições de calibre 7.62, não se achando presentes os requisitos ao reconhecimento do princípio da 'bagatela penal', por não ser reduzido o grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que, apesar da pequena quantidade, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade, tendo em vista que também houve a apreensão de drogas no interior de um guarda-roupa existente (...) Dessa forma, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp n. 1.960.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021) (Sublinhados meus).

Portanto, no que se refere ao crime do artigo 12, da Lei 10.826/03, a única solução é a sua censura pela prática de tal conduta.

Lado outro, com relação ao crime do artigo 35, caput, da Lei em assunto, o destino do trio de acusados é a absolvição.

Com relação a tal delito, a lei exige, além da pluralidade de pessoas, o animus associativo, a estabilidade, permanência e organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles, o que não se comprovou nos autos em relação a Hanes e Edilson.

Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação. (...) Associação - provas insuficientes. O crime em tela exige a vontade de dois ou mais agentes se associarem (animus associativo) e sua consumação se dá com a reunião estável e permanente, dispensando a prática do crime-fim. Não se demonstrou, contudo, mínima organização e hierarquia entre eles o que, após cotejar todos os elementos analíticos inseridos nos autos, não emerge com clareza meridiana o vínculo associativo. (...) Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão". (TJSP; Apelação Criminal 0002107-90.2016.8.26.0443; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017) (Ênfase minha).

Não por outro motivo, aliás, o próprio Ministério Público pugnou pela absolvição dos réus em relação a tal imputação.

Assim, a absolvição dos réus é imperiosa quanto a este delito.

Passo às penas, seguindo-se a ordem da denúncia.

a) EDILSON CARLOS GONÇALVES SANTANA JÚNIOR (crime do artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do CP):

Nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com preponderância às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a

natureza, quantidade, personalidade e conduta social.

Fixadas essas diretrizes, anoto que, embora o réu não apresente maus antecedentes (fls. 407/408), sua conduta extrapolou a normal à espécie.

Afinal, considerando que o tipo penal em questão visa tutelar o bem jurídico saúde pública, tão caro à sociedade, não valorar negativamente quem é pego na posse de 85 pinos plásticos contendo 'cocaína', com peso líquido de 34,3 gramas; 52 porções de 'maconha,' com peso líquido de 51,7 gramas; e uma porção à granel de 'cocaína', com peso líquido de 412,5 gramas; seria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas nas quais envolvem apreensão de pequena quantidade e uma única natureza de entorpecente.

Sendo assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na fase intermediária, a sanção permanece intacta.

Na última fase, por conta da incidência da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, conforme fundamentação supra, elevo a pena em 1/5 (um quinto), finalizando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras.

Esclareço ser inaplicável o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que os elementos probatórios revelaram a profunda intimidade do acusado com o narcotráfico, a despeito do documento de fls. 315.

Com efeito, não bastassem as quantidades e diversidades dos narcóticos transportados, Edilson trazia uma arma de fogo em sua cintura para a intimidação difusa e coletiva nessa vil atividade, demonstrando seu envolvimento perene no tráfico.

Neste mesmo sentido, trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.773.834/ES, REL. MINISTRA LAURITA VAZ. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE AFERIR O GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA OU DE SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO IDONEAMENTE JUSTIFICADO PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A motivação que ressalta a grande quantidade de entorpecente apreendido mostra-se em conformidade com a conclusão exarada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 27/11/2018 (DJe 19/12/2018), ao apreciar o REsp n. 1.773.834/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, em que decidiu que a elevada quantidade de droga apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. 2. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de balança de precisão é também circunstância que denota envolvimento com atividades criminosas. (...) 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1895691/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (Sublinhado meu).

Ou seja, a quantidade e diversidade de entorpecentes não são os únicos elementos a ensejar tal conclusão. Os elementos do caso concreto, indicam claramente que o réu é pessoa que se dedica à atividade criminosa, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena.

Aliás, como não existe prova direta dessa circunstância, dedicar-se à atividade criminosa, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", é exatamente essas circunstâncias que comprovam a sua dedicação, conforme julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Outro não é o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

"Tráfico de entorpecentes. (...) Insurgência defensiva em face da pena. Reprimendas irreprocháveis. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não fazem jus às acusadas. Dedicção à atividade criminosa. Volume considerável de droga que revela não serem as rés meras aventureiras no ramo da narcotraficância (...) Precedentes do STJ. Negado provimento ao apelo". (TJSP; Apelação Criminal 0002163-92.2017.8.26.0539; Relator: Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2020;

Data de Registro: 01/02/2020) (Originais sem marcações).

Assim, como determina a lei, tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, ainda que com outras ocupações lícitas, hipótese destes autos, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida do acusado.

Registro, por fim, que tal entendimento encontra-se em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que a quantidade de droga apreendida não foi o único elemento a ensejar a não aplicação do § 4º, do artigo em assunto, não podendo cogitar o proibido bis in idem.

A propósito, em recente julgado:

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados